

الفصل الأول:

التعريف بالقانون وخصائصه :

المبحث الأول : التعريف بالقانون :

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع ومقترنه بجزاء يوقع علي من يخالفها .
المبحث الثاني :

خصائص القاعده القانونيه :

اولا : انها قاعده عامه ومجرده .

ثانيا : القاعده القانونيه لا تحكم الا السلوك الظاهر .

ثالثا : القاعده القانونيه قاعده اجتماعيه .

رابعا : القاعده القانونيه مقترنه بجزاء مادي .

١- انها قاعده عامه ومجرده :

القاعدة القانونية عامة ومجردة، أي لا تُوجّه لشخص معين ولا لواقعة محددة، بل تطبق على كل من تتوافر فيه الشروط. وهي تخاطب الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم، حتى لو تعلقت بمنصب معين. ولا يشترط أن تكون دائمة أو مطبقة في كل إقليم الدولة، فقد تصدر لمدة محددة أو تطبق في مناطق معينة فقط.

٢- القاعده القانونيه لا تحكم الا السلوك الظاهر :

القانون ينظم السلوك الخارجي للأنفراد، ولا يهتم بما في النوايا والضمائر ما لم يتحول إلى أفعال مادية. فمجرد التفكير في الجريمة لا يُعاقب عليه القانون إلا إذا بدأ الشخص في التنفيذ. ومع ذلك، إذا ظهرت النية في شكل سلوك خارجي يدل عليها، فإنها قد تؤدي إلى تشديد العقوبة، مثل القتل مع سبق الإصرار أو بالسهم، حيث تكشف طريقة الفعل عن النية.

٣- القاعده القانونيه قاعده اجتماعيه :

القاعدة القانونية تهدف إلى تنظيم حياة المجتمع وحماية حقوق الأفراد وتحديد واجباتهم، ولا وجود لها دون مجتمع. وقد وُجد القانون قبل الدولة الحديثة، في المجتمعات القبلية والإقطاعية. ويختلف القانون باختلاف الزمان والمكان، ويتطور بتطور المجتمع ليستجيب لحاجاته الجديدة.

٤- القاعده القانونيه مقترنه بجزاء مادي :

القاعدة القانونية ملزمة لأنها تقتزن بجزاء تفرضه السلطة العامة على من يخالفها، مما يجبر الأفراد على احترامها. ولولا الجزاء لما ألزم الناس بالقانون بسبب تغلب المصالح الشخصية والأنانية. فالجزاء هو الذي يحقق الردع ويضمن احترام القاعدة القانونية.

المقصود بالجزاء :

الجزاء هو الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية، وهدفه إلزام الأفراد باحترام القانون وإصلاح آثار المخالفة. وهو ضروري لتحقيق النظام في المجتمع. ويتميز بأنه فوري، مادي، وتوقعه السلطة العامة.

تطور الجزاء :

بيد الدولة وليس انتقام فردي .

صور الجزاء :

١- الجزاء الجنائي :

الجزاء الجنائي هو أشد الجزاءات، ويُفرض على من يرتكب جريمة، وهي فعل غير مشروع يخلّ بنظام المجتمع، وتُقدّر خطورتها بمدى هذا الإخلال.

٢- الجزاء المدني :

الجزاء المدني يُوقع على من يخالف قاعدة تحمي حقًا أو مصلحة خاصة، وينظمه القانون المدني والتجاري. أنواع الجزاء المدني : الجزاء المباشر ، العيني ، الفسخ ، التعويض ، الإداري .

١- الجزاء المباشر :

يجبر الفرد على القيام بما لم يقم به طوعًا، مثل رد المال المسلوب، طرد المستأجر بعد انتهاء الإيجار، أو تنفيذ حكم مالي لاستيفاء حق الدائن.

٢- الجزاء العيني :

هذا النوع من الجزاء يهدف إلى إعادة الحالة لما كانت عليه قبل المخالفة، سواء بمخالفة مادية (مثل هدم بناء) أو بإبطال التصرف المخالف للقانون، بحيث لا يلزم الشخص المخالف تجاه الغير إلا ضمن حدود القانون.

٣- الفسخ :

الفسخ هو جزاء مدني يعيد الحالة لما كانت عليه قبل العقد، مثل فسخ البيع إذا لم يسلم البائع المبيع أو لم يدفع المشتري الثمن.

٤- التعويض :

الجزاء المدني قد يكون تعويضًا نقديًا لإصلاح الضرر أو جبر خاطر المضرور، وقد يكون جزاء أصليًا، بديلًا، أو مكملًا للجزاء الأصلي حسب الحالة.

٥- الجزاء الإداري :

الجزاء الإداري توقعه السلطة الإدارية على المخالفين للأوامر أو اللوائح، مثل الإنذار أو الخصم أو الفصل، ويستند إلى المبادئ العامة للقانون دون نصوص محددة لكل مخالفة.

قارن بين الجزاء الجنائي والجزاء المدني :

الجزاء الجنائي :

الجزاء الجنائي هو رد فعل المجتمع على المخالف، مثل الحبس أو الغرامة، ويُطالب به النيابة العامة عبر الدعوى الجنائية أمام القضاء الجنائي للدفاع عن المجتمع.

الجزاء المدني :

الجزاء المدني للجريمة يهدف إلى إصلاح الضرر وتعويض المضرور، ويختص القضاء المدني بالنظر فيه. ويمكن للمجني عليه أن يرفع دعوى مدنية ضمن الدعوى الجنائية للحصول على التعويض أو استرداد الحقوق، كما في حالات السرقة أو القتل أو الجرح.

الفصل الثاني : تفريد القواعد القانونية عن غيرها :

أولاً : القواعد القانونية، وقواعد المجاملات والعادات والتقاليد :

قواعد المجاملات والعادات والتقاليد هي مبادئ يلتزم بها الناس في حياتهم اليومية بسبب تعارف المجتمع عليها واحترامه لها، مثل التهنية في الأفراح، والتعزية في الأحزان، ومساعدة المحتاج، وتبادل التحية. هذه القواعد تؤثر في سلوك الأفراد وتدفعهم للالتزام بها خوفاً من لوم الضمير واستنكار الناس. لكن الجزاء عند مخالفتها يكون معنوياً فقط، كالاستهجان الاجتماعي، وليس جزاءً قانونياً ملزماً.

ثانياً : القواعد القانونية وقواعد الأخلاق :

الأخلاق هي معاني الخير في السلوك، يحرص المجتمع على احترامها، وتهدف إلى نشر الفضائل، ومحاربة الرذائل، وحفظ القيم الأساسية، وهي غاية دينية وإسلامية.

١- أوجه التشابه بين الأخلاق والقانون :

تتشابه القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية في كونهما قواعد عامة وملزمة لجميع أفراد المجتمع، وتقتربان بجزاء عند المخالفة، وتهدفان إلى تنظيم الحياة وتوجيه السلوك لتحقيق رقي المجتمع وسعادته.

٢- أوجه الاختلاف بين الأخلاق والقانون :

أ- اختلاف الجزاء في كل منهما :

يختلف الجزاء في القاعدة القانونية عن القاعدة الأخلاقية؛ فالجزاء في القاعدة القانونية مادي توقعه السلطة العامة، أما في القاعدة الأخلاقية فهو معنوي يتمثل في تأنيب الضمير واستنكار المجتمع دون وجود سلطة تلزم به.

ب- اختلاف الغاية في كل منهما :

يختلف هدف القاعدة القانونية عن القاعدة الأخلاقية؛ فالقاعدة القانونية تهدف إلى تحقيق نفع المجتمع وحماية مصالحه، أما الأخلاق فتهدف إلى الارتقاء بالمجتمع نحو السمو والكمال.

ج- مصدر الالتزام في كل منهما :

تختلف القاعدة القانونية عن القاعدة الأخلاقية في المصدر؛ فمصدر القاعدة القانونية محدد وواضح، أما مصدر القاعدة الأخلاقية فغير محدد ويتمثل في ضمير الأفراد وسلوكهم ويتغير باختلاف الأشخاص والأزمان.

د- من حيث الاعتداد بالنوايا والسلوك الظاهر :

القاعدة القانونية تهتم بالسلوك الظاهر فقط لأن البشر لا يعلمون ما في النفوس، أما القاعدة الأخلاقية فتركز على الضمير وتهذيبه للارتقاء بالسلوك والوصول بالإنسان نحو الكمال.

صلة الأخلاق بالقانون :

رغم اختلاف القانون عن الأخلاق، فلا يوجد انفصال بينهما لأن غايات القانون هي في أصلها غايات أخلاقية، كحفظ الحقوق والوفاء والبعد عن الغش والسرقة. ومع ذلك تبقى للأخلاق مجالات خاصة لا يتدخل فيها القانون، مثل الصدق ونبذ الحقد والكراهية.

ثالثاً : مبادئ القانون وأحكام الدين :

الدين هو ما شرعه الله على يد أنبيائه ورسله، ويختلف باختلاف كل رسالة، لكنه يتفق على حماية مقومات الحياة الأساسية: الدين، النفس، العرض، العقل، والمال. الفروع تختلف بحسب الزمان والمكان، لكن الغايات واحدة. خاتم الرسالات هو الإسلام برسالة محمد ﷺ التي جمعت كل شرائع السماء.

الدين ينظم كل علاقات الإنسان:

علاقته بالله بالعبادات، حيث تقوم على الواجب المطلق للعبد، وعلاقاته بالمجتمع والناس، وعلاقته بنفسه وحق النفس في الحفظ وعدم الظلم. يشمل الدين قواعد سلوكية ملزمة، مرتبطة بجزاء لضمان احترامها وتنفيذها. وبذلك يكون الدين أشمل من القانون في تنظيم حياة الفرد والمجتمع.

الفرق بين قواعد الدين وقواعد القانون:

١- اختلاف المصدر:

يختلف مصدر القاعدة الدينية عن القاعدة القانونية؛ فمصدر القاعدة الدينية سماوي من كتاب الله وسنة النبي وإجماع العلماء، أما القاعدة القانونية فمصدرها وضعي من نصوص وضعها أهل الرأي أو السوابق القضائية، وهذا الاختلاف يمثل فرقاً جوهرياً بينهما.

٢- اختلاف الجزاء:

يختلف الجزاء في القاعدة الدينية عن القانونية؛ فالدينية تشمل جزاء دنيوي وأخروي، ويحاسب الله على الجزاء الأخروي، بينما القانونية جزاؤها معجل في الدنيا فقط ويوقعه السلطة العامة.

٣- اختلاف المحل:

هم امرين:

الامر الاول:

بعض الجرائم مثل القتل والسرقة مؤثمة في الشريعة والقانون معاً، ويُعاقب عليها كلاهما، رغم اختلاف فلسفة العقوبة، ويظل هناك تشابه في التجريم وحماية المصلحة العامة.

الامر الثاني:

القانون يستند إلى أحكام الدين في تنظيم العلاقات وفرض العقوبات، وإذا خالف حكم القانون الشريعة الإسلامية يفقد شرعيته وصلاحيته، ويحق الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.

الفصل الثالث:

دور القانون في تنظيم نشاط المجتمع

المبحث الاول: الأساس العملي للقانون:

غاية القانون هي تنظيم سلوك الأفراد، وإلزامهم باحترامه وتطبيقه، سواء اختياراً أو إجباراً، وهو أداة بيد الدولة تفرض بها سيطرتها وتوجه أهداف المجتمع.

مدي تدخل القانون لتنظيم شؤون المجتمع؟

ترتبط الإجابة على هذا التساؤل بالفلسفة والفكر السائد في المجتمع، سواء كان اشتراكياً أو رأسمالياً أو بينهما.

اولاً: المذهب الفردي:

المذهب الفردي يقوم على أن الفرد هو محور المجتمع، وأن القوانين والأنظمة يجب أن تخدمه وتحقق إرادته دون قيود كبيرة. يتيح حرية اختيار النشاط والتملك، ولذلك يُعرف بالمذهب الرأسمالي. رغم ذلك، يعيش الفرد ضمن جماعة تتفاعل فيما بينها، والقانون يسعى لموازنة إرادات الأفراد المتنافسة. أنصار المذهب يؤكدون أن المجتمع وُجد لخدمة الفرد، وكل مؤسساته يجب أن تُسخر لإسعاده وتحقيق مصالحه. يركز المذهب على التوفيق بين الحرية الفردية والتعايش الاجتماعي ضمن إطار يحفظ حقوق الجميع.

اساس المجتمع في ظل المذهب الفردي:

المذهب الفردي يقوم فقط في بيئة تدعمه، من خلال المجالين الاقتصادي والسياسي لضمان حرية الفرد وحمايته.

١- في المجال الاقتصادي:

المذهب الفردي يقوم على أن الفرد ولد حراً وله الحق في ممارسة نشاطه وامتلاك عوائده، مع احترام حقوق الآخرين. لحماية الجميع، تُفقد الحقوق الفردية بحيث لا تُضر بحرية الآخرين. وظيفة القانون هي توفير الظروف التي تمكن الفرد من ممارسة حقوقه وحرية مع منع الاعتداء على حقوق الآخرين، وتقتصر وظيفة الدولة على حفظ الأمن داخلياً وخارجياً.

٢- وفي المجال السياسي:

فلسفة المذهب الفردي تستند إلى فكرة العقد الاجتماعي، التي ترى أن المجتمع يقوم على اتفاق بين الأفراد والدولة لتنظيم الحياة وحماية الحقوق. في الأصل، كان الأفراد أحراراً ومعزولين، ثم تنازلوا عن جزء من حقوقهم الطبيعية مقابل حماية الدولة وتوفير المرافق اللازمة لنشاطهم. الدولة في هذه الفلسفة مهمتها حماية الحقوق الطبيعية المتبقية للأفراد، مع اعتبار العقد الاجتماعي فكرة افتراضية لتفسير نشأة المجتمع.

نتائج المذهب الفردي:

المذهب الفردي يؤدي، وفق فلسفته، إلى نتائج مهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية.

١- في المجال السياسي :

أولى نتائج المذهب الفردي أن الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الحقوق والواجبات، والحرية والمساواة هما الحقان الطبيعيان. وظيفة القانون هي التوفيق بين الحريات والحقوق الفردية، مع تقييدها بالحد الأدنى الضروري لحماية حرية المجتمع، بينما يترك النشاط الفردي يتسع إلى أقصى مدى ممكن.

٢- وفي المجال الاقتصادي :

المذهب الفردي يطلق حرية المنافسة الاقتصادية باعتبارها المظهر الاقتصادي للحرية الفردية، ويترك المجال مفتوحاً دون تدخل الدولة. وفق آدم سميث، سعي الأفراد لتحقيق مصالحهم الاقتصادية الخاصة يؤدي تلقائياً إلى منفعة المجتمع.

٣- وفي المجال القانوني :

المذهب الفردي يجعل الإرادة الحرة والعقد في المقام الأول، فكل ما يوافق عليه الفرد يعد حقاً وعدلاً. تخضع العقود فقط لإرادة المتعاقدين. هذا هو مبدأ سلطان الإرادة في القانون.

هذا المبدأ تفرع منه نتيجتان مهمتان :

اولهما :

كل الالتزامات والحقوق القانونية تقوم على الإرادة الحرة، فلا يلتزم أحد بعقد إلا بإرادته أو بواسطة وكيله. الأسرة والملكية تقوم أيضاً على حرية الإرادة. حتى مشروعية العقوبة الجنائية تُستند إلى إرادة الفرد، لأنه يفترض علمه بالقانون قبل ارتكاب المخالفة.

ثانيهما :

الإرادة هي المرجع الأساسي في إنشاء الالتزامات وآثارها. ما يوافق عليه الفرد يعد حقاً وعدلاً، ولا يجوز له التحلل من التزامه بدعوى الغبن أو الظلم. لذلك، لا يتدخل القاضي لتعديل الالتزامات بناءً على فكرة العدالة.

تقييم المذهب الفردي :

رغم بريق مبادئه، تعرض المذهب الفردي للنقد لأنه بالغ في تمجيد الحرية الفردية على حساب الصالح العام، معتبراً أن الاهتمام بالمصلحة الفردية يكفي لتحقيق الصالح العام. لكن هناك مصالح عامة كالصحة والتعليم والدفاع والسياسة الخارجية لا يمكن للأفراد العناية بها بمفردهم. الإفراط في الحرية الفردية خلق أنانية وفجوة بين الأغنياء والفقراء، وأدى إلى ضعف التواصل الاجتماعي وتآكل الوحدة بين فئات المجتمع. كما أن فكرة حقوق الفرد المنعزل كانت خيالية ولا وجود لها واقعياً.

ثانياً : المذهب المجتمعي :

المذهب الاشتراكي يركز على المجتمع ويعتبر الفرد وسيلة لخدمته، ويتدخل القانون في حياة الفرد وحرياته إلى أقصى حد، وتتسع دائرة القانون فيه مقارنة بالمذهب الفردي. يقوم هذا المذهب على أن الإنسان كائن اجتماعي، والمجتمع وحدة متجانسة يجب أن تُوجّه جهود أفرادها نحو الصالح العام، فلا ينظر إلى الفرد ككيان مستقل منعزل. مصدر القانون هنا هو الضرورات والحاجات الاجتماعية، ووظيفته الأساسية توجيه النشاط الفردي لخدمة المجتمع، وليس مجرد حماية الحقوق الفردية أو سعادة الفرد. القانون يقوم بدور إيجابي لإصلاح عيوب الحرية الفردية وسد نقصها، والحرية الفردية ليست حقاً طبيعياً بل منحة يمنحها المجتمع وفق مصالحه. بعض رواد المذهب ذهبوا إلى إلغاء استقلالية الفرد أو توجيه الملكية الفردية لصالح الجماعة، معتبرين الملكية وظيفة اجتماعية. لا يجوز للإرادة الفردية تجاوز نصوص القانون، فالقانون أداة الدولة لتوجيه نشاط الأفراد وفق خطط مرسومة. المساواة هنا هدف رئيسي، لكنها لا تعني مساواة فعلية دائماً، لأن الأفراد يختلفون اجتماعياً من حيث القوة والضعف. القانون يستخدم لضمان أن الأقوياء لا يستغلون الضعفاء، والحرية الفردية تُمنح وفق تقدير المجتمع واحتياجاته. المذهب الاشتراكي يختلف في تطبيق مبادئه بين التطرف والاعتدال لتحقيق المساواة المنشودة. نطاق القانون أوسع بكثير مقارنة بالمذهب الفردي، ويهدف لتحقيق الصالح العام للمجموعة.

ويظهر اتساع نطاق القانون في المذهب الاشتراكي من خلال امرين هما :

١- النصوص التشريعية الامر :

النصوص القانونية إلزامية، وأي اتفاق يخالفها باطل، والعمل يقتصر على ما يقرره المشرع.

٢- الشكلي في النص القانوني :

الشكليّة نظام قانوني يوجب أن يكون التصرف وفق الشكل الذي يحدده القانون، وإلا يكون باطلاً قانونياً. غالباً يكون هذا الشكل كتابة رسمية كما في هبة العقار، أو كتابة عرفية كما في عقد الشركة المدنية، أو تسليم الشيء كما في هبة المنقول. وفي المذهب الاشتراكي، لم يتفق أصحاب المذهب على مدى تدخل القانون؛ بعضهم دعا لإلغاء الملكية الخاصة وجعل الدولة مالكة لوسائل الإنتاج، والبعض الآخر سمح بالملكية الخاصة مع وضع قيود لتحقيق الصالح العام.

تقييم المذاهب المجتمعية :

- ١- أظهرت المذاهب المجتمعية سلبية المذهب الفردي، حيث تبين أن سعادة المجتمع لا تتحقق إذا تركت الحرية المطلقة للأفراد. الحرية الفردية وفق المصالح الخاصة أدت إلى ظلم اجتماعي وانحراف بعض الطبقات عن الحقوق القانونية. هذا تسبب في عرقلة تقدم المجتمع وحصر وسائل الإنتاج. كما أدى إلى تفرغ العمال للإدارة والقيادة على حساب الإنتاج الفعلي.
- ٢- من عيوب المذهب الاشتراكي أن الإفراط في تدخل الدولة قد يؤدي إلى فقدان الحافز الشخصي وضياح أثر المجهود الفردي. ومع ذلك، كثير من الدول لم تصل لهذا التطرف، بل تحترم الحرية الفردية ضمن حدود القانون. كما تحترم الملكية الفردية مع وضع قيود لضمان أدائها لوظيفتها الاجتماعية.

أثر المذهبين في القانون المصري :

تأثر القانون المصري بالمذهبين الفردي والاشتراكي تاريخياً. بدأ بالفردي مع حرية الفرد والنشاط الاقتصادي الخاص، ثم تحول إلى الاشتراكي بسيطرة الدولة على الإنتاج. لاحقاً عاد الفكر الفردي تدريجياً عبر خصخصة وسائل الإنتاج. هذا يعكس توازن متغير بين دور الدولة وحرية الفرد.

ثالثاً : الفكر القانوني المعاصر :

النزعة الاشتراكية في مصر ظهرت في تشريعات الإصلاح الزراعي والتأمين والقوانين العمالية، التي منحت العمال والفلاحين حقوقاً واسعة وحماية قانونية قوية، بما في ذلك المشاركة في النقابات والمجالس الإدارية والتشريعية. هذه الحماية المبالغ فيها أضعفت المصلحة العامة، إذ ركزت على طرف دون الآخر، ما أدى إلى تراجع الإنتاج في المصانع الكبرى مثل النسيج والحديد والصلب والألبان. المؤسسات الاستهلاكية أيضاً تأثرت بالخسائر بسبب التسبب وعدم الحرص على زيادة الإنتاج والمصلحة العامة، بينما كانت إجراءات العقاب على العمال محدودة ومشددة بحيث جعلتهم محصنين في غالب الأحيان. نتيجة هذه التجربة، ظهرت الحاجة لإصلاح الوضع عبر الخصخصة والعودة إلى الفكر الرأسمالي والمذهب الفردي في الإنتاج وإدارة العمال. هذا التوجه لا يزال في بدايته لكنه يشهد تطوراً ملحوظاً نحو إعادة التوازن بين حقوق العمال والمصلحة العامة.

المبحث الثاني : نطاق تدخل القانون من خلال القواعد الامره والقواعد المكمله

المطلب الاول : القواعد القانونية الامره :

القواعد القانونية الأمرة هي قواعد ملزمة لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها أو استبعاد أحكامها. يفرضها المشرع لتحقيق المصلحة العامة وحماية النظام العام والآداب. تُستخدم لتنظيم المصالح الأساسية في المجتمع مثل الأمن الداخلي والخارجي ونظام الأسرة. كما تنظم شؤون الدولة والسياسة الاقتصادية. وتشمل أيضاً تحديد شكل التمثيل البرلماني، مثل اشتراط تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن ٥٠%.

مجال القواعد القانونية الامره :

القواعد القانونية الأمرة تتعلق بالمصالح الأساسية في المجتمع ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها. من أمثلتها تحريم القتل والمخدرات والربا وتحديد حد أقصى للعائد. كما تشمل أحكام الأسرة مثل المحرمات والطلاق والعدة والنسب والضرائب. وكل اتفاق يخالفها يعد باطلاً لمخالفته النظام العام والآداب.

المطلب الثاني : القواعد القانونية المكمله أو المفسره :

القواعد القانونية المقررة أو المفسرة هي قواعد يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها دون بطلان. وضعها المشرع لمساعدة الأفراد في تنظيم اتفاقاتهم وعقودهم. تمثل هذه القواعد الرضا المفترض بين الأطراف عند غياب الاتفاق الصريح. تُستخدم لتفسير الإرادة الغامضة وتنظيم المسائل التي لم يحددها المتعاقدون. ومن أمثلتها تحديد وقت ومكان تسليم المبيع وضمان عيوبه في عقد البيع.

حدود الالتزام في القواعد المكمله :

القواعد المكمله ليست غير ملزمة، بل هي ملزمة كغيرها من القواعد القانونية. لكنها لا تُطبق إلا إذا لم يتفق الأفراد على مخالفتها. فإذا لم يوجد اتفاق مخالف، أصبح حكمها ملزماً لهم. ولا يصح القول بأنها اختيارية في البداية وملزمة في النهاية، لأن الإلزام صفة أساسية في كل قاعدة قانونية. الفرق بينها وبين القواعد الأمرة أن تطبيقها مشروط بعدم الاتفاق على خلافها.

ويهتدي المشرع في وضع القواعد المكمله لاراده الافراد باعتبارين :

اولهما : انه ينظم العلاقة القانونية وفق ما يُفترض أن يكون عليه اتفاق الطرفين، كما في العقود التجارية كالبيع والإيجار.

ثانيهما : في حالات أخرى يُراعى تنظيم المعاملات وفق العادات، أما القواعد الأمرة فيفرضها المشرع لأنها تتعلق بمصالح المجتمع ولا تُترك لإرادة الأفراد.

المطلب الثاني : معيار التفرقة بين القواعد الامرء والقواعد المكمله :

تنقسم القواعد القانونية إلى أمرء ومكمله، ويُفرّق بينهما بالمعيارين: الشكلي والموضوعي.

الفرع الاول : المعيار الشكلي :

المعيار الشكلي يميز القاعدة الأمرء عن المكمله من خلال صياغة النص، مثل التحذير من مخالفتها أو فرض العقوبة أو البطلان على المخالف.

ومن ذلك :

- ١- تنص المادة (٤٨) مدني على أنه: "لا يجوز لأحد التخلي عن أهليته أو التعديل في أحكامها".
- ٢- القواعد القانونية تنقسم إلى أمرء ومكمله. المواد (١٣١، ٤٩، ١٧، ٣١، ١٠٣ مدني) جاءت بصيغة أمرء. لا يجوز مخالفة هذه النصوص بأي حال. المخالفة تؤدي إلى البطلان أو العقوبة أو عدم الاعتداد بالاتفاق.
- النصوص المكمله تُطبق إلا إذا وُجد اتفاق أو عرف يخالفها. مثل المادة (٤٥٦ مدني) بشأن مكان استحقاق الثمن.
- وأيضاً المادة (٤٤٨ مدني) بشأن مصروفات عقد المقيضة. بهذا يُميز بين القواعد الأمرء التي لا تُعدل، والمكمله التي يمكن تعديلها بالاتفاق.

وذلك كما في النصوص الآتية :

- ١- المادة ٤٥٦ مدني تنص على أن الثمن مستحق الوفاء في مكان تسليم المبيع، إلا إذا وُجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
- ٢- المادة ٤٤٨ مدني: يتحمل المتقايضان مصاريف العقد مناصفة إلا إذا اتفقا خلاف ذلك.
- ٣- المادة ١٠٣ مدني: دفع العربون يمنح الحق في العدول إلا إذا نص الاتفاق خلاف ذلك.
- ٤- المادة ٥٨٦/٢ مدني: تُدفع الأجرة في موطن المستأجر إلا إذا وُجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، ويبين النص طبيعة الالتزام إذا كان مكملًا أو أمراً.

الفرع الثاني : المعيار الموضوعي :

عند غياب وضوح النص في كونه أمراً أو مكملًا، يُنظر إلى أساس الحكم وصلته بالمصالح العامة، فالأحكام المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة تُعد قواعد أمرء لا يجوز مخالفتها، لذا يجب تحديد معنى النظام العام والآداب.

اولا : المقصود بالنظام العام :

النظام العام هو الإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي الذي يقوم عليه المجتمع، وتشمل قواعده كل ما يتعلق بالمصالح الأساسية العليا وتعتبر أساساً للقانون في الدولة.

مرونة فكرة النظام العام :

النظام العام فكرة نسبية ومرنة، تتغير من بلد لآخر ومن زمان لآخر وفق تطور المجتمع ومبادئه. في الدول الفردية تُوسع حرية الإرادة وتقلص تدخل الدولة، أما المذهب الاشتراكي فيزيد حماية بعض المصالح الخاصة باعتبارها عامة. ما يُعد من النظام العام في بلد قد يكون مخالفاً في بلد آخر، مثل الجمع بين الزوجات وحق الطلاق. النظام العام يتغير مع الزمن، كما في فرنسا حيث سمحت المحاكم بشرط يمنع التصرف في الملكية مؤقتاً عند وجود مصلحة جدية. المشرع لم يحدد النظام العام بدقة، تاركاً مهمة تحديده للقضاء. القاضي يستند في ذلك إلى المبادئ الأساسية للنظام الاجتماعي والقانوني في بلده. القضاء يخضع لرقابة محكمة النقض ويتأثر بالتغيرات الخلقية والاجتماعية والسياسية السائدة.

النظام العام في إطار القانون العام :

معظم أحكام القانون العام من النظام العام لحماية نظام الدولة السياسي والدستوري والإداري والمالي. الحقوق والحريات العامة مثل الانتخاب وحرية العقيدة والتنقل لا يجوز التنازل عنها. الوظائف العامة والضرائب والخروج عن القوانين الجنائية باطل إذا تم الاتفاق عليه. قوانين التنظيم القضائي أيضاً من النظام العام لضمان تنظيم السلطة القضائية وحماية مصالح الدولة.

النظام العام في دائرة القانون الخاص :

في القانون الخاص، تظهر فكرة النظام العام بدرجة أقل، خصوصاً في الدول الفردية، بينما تدخل بعمق أكبر في الدول الاشتراكية.

و تأثير النظام العام في القانون الخاص يختلف حسب نوع الروابط، فهو أقوى في الأحوال الشخصية وأضعف في المعاملات المالية والنظام العام.

ولهذا ينبغي بيان الفرق بينهم :

النظام العام وروابط العلاقات الاسريه : الأحوال الشخصية تتعلق بحالة الشخص وأهليته وتنظيم الأسرة، وهي من النظام العام. و جميع قواعد الأهلية أسرة، والمادة ٤٨ مدني تمنع النزول عنها أو تعديلها. مثال: سن الرشد ٢١ سنة، والقاصر لا يتنازل عن حقوقه عند البلوغ. الطلاق والحضانة والطاعة والولاية تهدف لحماية الأسرة وضمان استقرارها.

٢- النظام العام والروابط الماليه :

تنظيم الروابط المالية يعتمد أساساً على حرية الأفراد وسلطان إرادتهم، لكن بعض الجوانب قد تتطلب تدخل الدولة بقواعد أسرة لحمايتها وتنظيمها.

ويمكن ارجاع المسائل الماليه المتصله بالنظام العام فيما يأتي :

١ () القواعد المتصله بالشكل :

التصرفات القانونية أساسها الرضا وتتم بالتراضي. بعض العقود تشترط الشكل الرسمي ليكون صحيحاً. الهيئة مثلاً على ذلك (المادة ٤٤٨ مدني). لرهن أيضاً يحتاج إلى ورقة رسمية (المادة ١٠٣١ مدني). عدم الالتزام بالشكل يؤدي إلى بطلان العقد.

ب () القواعد المتعلقة بمراعاة احد المتعاقدين :

القانون يحمل كل طرف حماية مصالحه، لكن في بعض العقود يكون أحد المتعاقدين أضعف من الآخر. لذلك وضع المشرع نصوصاً أسرة لحماية الطرف الضعيف. مثل قواعد عقد العمل وعقود التأمين وعقود الإذعان. تشمل أيضاً حماية الإرادة من العيوب كالتدليس والإكراه والاستغلال. تهدف هذه القواعد لمنع فرض شروط تعسفية وضمان عدالة العقود.

ج () القواعد المنظمه للحقوق العينية العقاريه :

قواعد تنظيم الملكية قواعد أسرة لكون الملكية من النظم الأساسية في المجتمع. تشمل تسجيل التصرفات العقارية والحقوق العينية كالارتفاق والرهن. لا تنشأ الملكية أو الحق العيني على العقار ولا يُحتج به على الغير إلا بتسجيله حسب قانون الشهر العقاري. هذه القواعد من النظام العام ولا يجوز مخالفتها.

د () القواعد المتعلقة بالصالح الاقتصادي العام :

مثل تنظيم الائتمان وتسعير السلع وإعطاء آجال للمدينين، وفرض سعر إلزامي للأوراق البنكية، وتحديد سعر العائد. كلها قواعد أسرة لارتباطها بالنظام العام.

ثانيا : الاداب العامه :

الآداب العامة جزء من النظام الأخلاقي الذي يعتبره المشرع أساساً للتنظيم القانوني. تتشكل هذه القواعد من المعتقدات والعرف المتوارث بين الناس. الآداب العامة نسبية ومرنة، تختلف باختلاف الزمان والمكان. ما يُعد مخالفاً للآداب في بلد أو وقت قد لا يكون كذلك في آخر.

مثال: التأمين على الحياة كان يُعتبر مخالفاً للآداب العامة عند ظهوره. لاحقاً أقره القانون بعد وضع قواعد تحمي الأخلاق العامة. القضاء يبطل الاتفاقات التي تهدف لعلاقات جنسية غير مشروعة أو أنشطة محرمة. الهدف من الآداب العامة حماية المجتمع وضمان توافق القوانين مع الأخلاق والمبادئ الاجتماعية.

الفصل الأول : فروع القانون العام

المبحث الاول : القانون الدولي العام

القانون الدولي العام ينظم تصرفات الدول وعلاقاتها في السلم والحرب. يوضح حقوق وواجبات الدول، مثل السيادة والمساواة والاحترام المتبادل، وحدود إقليمها. ينظم الوسائل الودية لفض النزاعات، مثل المفاوضات والتحكيم، ويعرف ذلك بقانون السلم. وعند فشلها، يحدد قواعد الحرب والحياد، وحقوق وواجبات الدول المحاربة والمحايدة.

مصادر القانون الدولي العام :

١- العرف :

العرف هو أهم مصدر للقانون الدولي العام، على عكس القانون الداخلي حيث يأتي بعد التشريع. يتكون العرف الدولي من تكرار سلوك مماثل لدول مختلفة مع اعتقادها بوجوب الالتزام به.

وقد يكون العرف إقليمياً إذا اقتصر على مجموعة دول أو منطقة محددة. وقد يكون عاماً أو دولياً إذا تناول الشؤون الدولية بشكل عام.

٢- المعاهدات الشارعة :

المعاهدات الدولية هي اتفاقات تحدد أو تنشئ قواعد القانون الدولي العام أو تعديلها أو تلغيها. والمعاهدات الخاصة تبرم بين عدد محدود من الدول وتلزم المتعاقدين فقط، وقد تتحول إلى قاعدة عرفية إذا تكررت. والمعاهدات العامة تبرم بين عدد كبير من الدول وتهدف إلى وضع قواعد دولية عامة، وتسمى اتفاقات شارعة. أمثلة على ذلك اتفاقيات لاهاي (١٨٩٩، ١٩٠٧) وميثاق الأمم المتحدة (١٩٤٥)، التي تنظم الحرب وتسوية المنازعات الدولية.

٣- المبادئ القانونية العامة :

القانون الدولي العام يقوم على مبادئ أساسية مثل مسؤولية من يسبب الضرر، احترام العقود، والظروف الطارئة. هناك خلاف فقهي حول ما إذا كانت قواعد تعتبر قواعد قانونية بالمعنى الصحيح، بسبب ضعف آليات الجزاء. بعض الفقهاء يرون أن المجتمع الدولي يفرض الدول المعتمد عليها بتطبيق الجزاء، لكن ذلك غير فعال مع الدول الضعيفة. رغم ذلك، القانون الدولي معترف به من جميع الدول، وقواعده تتحسن تدريجياً مع تطور العلاقات الدولية والتقدم العلمي، حتى يمكن أن تُطبق بشكل عالمي يوحد المجتمع الدولي.

المبحث الثاني : القانون العام الداخلي

المطلب الأول : القانون الدستوري

القانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام يحدد شكل الدولة ونوع الحكومة، وينظم السلطات العامة وعلاقتها ببعضها، ويبين الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. الدستور هو المصدر الأساسي لهذا القانون، سواء كان مكتوباً أو عرفياً، ويحدد كيفية تشكيل السلطات واختصاصاتها. الدساتير تختلف في طريقة وضعها: قد تكون منحة، أو عبر جمعية تأسيسية، أو استفتاء شعبي، أو ناشئة عن العرف والتقاليد. كما تختلف في مرونتها؛ فبعضها قابل للتعديل بسهولة، وبعضها جامد ويعدل بآليات خاصة منصوص عليها.

المطلب الثاني : القانون الإداري

القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام ينظم نشاط الدولة الإداري والمرافق العامة وعلاقتها بالجمهور. وظائف الدولة الثلاث هي: التشريعية لتنظيم العلاقات، القضائية لحماية الحقوق، والإدارية لتقديم الخدمات وإدارة المرافق العامة. السلطات الإدارية، سواء مركزية أو محلية أو إقليمية، تدبر المرافق العامة باستخدام سلطات تنظيمية وإدارية وتأديبية. السلطة التنفيذية تقوم بأعمال سيادة مثل إعلان الحرب، وأعمال إدارية مثل إصدار القرارات وتنظيم شؤون المجتمع.

ويدخل في نطاق القانون الإداري الموضوعات :

أولاً: القانون الإداري يحدد العاملين بالمرافق العامة، وحقوقهم وواجباتهم، وسلطات الجهات الإدارية وامتيازاتها.
ثانياً: أموال المرافق العامة هي الأموال المنقولة والعقارية المستخدمة من قبل السلطات الإدارية لإدارة هذه المرافق.
ثالثاً: يشمل القانون الإداري تنظيم استغلال وإدارة المرافق العامة، ويختص القضاء الإداري بفض النزاعات المتعلقة بها بشكل مستقل عن القضاء المدني.

مصادر القانون الإداري :

القانون الإداري حديث النشأة وظهر لاستقلاله عن القانون المدني في تنظيم علاقات الدولة مع الأفراد. أخذت قواعده تتطور أولاً في فرنسا ثم وصلت إلى مصر مع إنشاء مجلس الدولة للنظر في المنازعات الإدارية، بينما ظل القضاء المدني مختصاً بدعوى التعويض المدني ضد الإدارة.

ولهذا يمكن اعتبار تلك المصادر كما يلي :

أولاً: القانون المدني والقوانين الخاصة مصدر لكثير من أحكام وقواعد القضاء الإداري في مصر.

ثانياً: القضاء الإداري يضع مبادئ قانونية مستنداً إلى السوابق القضائية، لذا يُقال إن القانون الإداري قانون قضائي من صنع القضاء.

ثالثاً: تشريعات القانون الإداري متفرقة وليست موحدة، فهي موجودة في الدستور وقوانين ولوائح مختلفة مثل قوانين الموظفين، الإدارة المحلية، مجلس الدولة، والمرافق العامة.

رابعاً: لم يصدر بعد قانون خاص بإجراءات القضاء الإداري، لذا ينظم قانون مجلس الدولة رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ بعض الإجراءات ويُحال إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية لحين صدور القانون الخاص.

مميزات القانون الإداري :

- ١- القانون الإداري غير مقنن، وقواعده متناثرة في قوانين ولوائح متعددة، ما أتاح للقضاء ابتكار أحكام استناداً إلى المبادئ العامة للقانون، ويُعرف هذا بالإبداع القضائي.
- ٢- أغلب أحكام القانون الإداري هي من ابتكار مجلس الدولة نتيجة غياب نصوص قانونية مكتوبة في كثير من مجالاته.
- ٣- قواعد القانون الإداري متغيرة ومتطورة لأنها توفق بين احتياجات الإدارة وحماية حقوق الأفراد، بسبب غياب نصوص قانونية محددة.

المطلب الثالث : القانون المالي

القانون المالي ينظم مالية الدولة من إيرادات ومصروفات، ويحدد طرق جباية الموارد وإنفاقها، وقد استقل عن القانون الإداري وأصبح فرعاً مستقلاً.

موضوعات القانون المالي :

القانون المالي يختص بميزانية الدولة من إيرادات ومصروفات، حيث تشمل الإيرادات الضرائب، رسوم الخدمات، أموال الدولة الخاصة والقروض، بينما تشمل المصروفات النفقات على المرافق العامة، رواتب الموظفين، وبرامج التكافل الاجتماعي.

المطلب الرابع : القانون الجنائي

قانون العقوبات يحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها، ويبين الإجراءات لتتبع المتهم ومحاكمته وتنفيذ العقوبة. وينقسم إلى فرعين :

- الاول : قانون العقوبات هو فرع من القانون الجنائي يحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها.
- الثاني : قانون الإجراءات الجنائية يختص بالإجراءات المتبعة في محاكمة المتهمين وتنفيذ العقوبة المقررة عليهم.

١- القسم الاول وهو قانون العقوبات فينقسم بدوره الى قسمين :

١- القسم العام من قانون العقوبات ٢- القسم الخاص من قانون العقوبات

المسائل التي ينظمها القسم العام يتولى القسم العام من قوانين العقوبات تنظيم الموضوعات الاتية :

- ١- بيان المبادئ العامة للمسؤولية الجنائية دون التعرض للأحكام الخاصة بكل جريمة على حده
- ٢- الجرائم تنقسم إلى مخالفات وعقوبتها الحبس $\geq$ أسبوع أو غرامة ≥ ١٠٠ جنيه، جنح وعقوبتها الحبس $<$ أسبوع أو غرامة < ١٠٠ جنيه، وجنايات وعقوبتها السجن أو الأشغال الشاقة أو الإعدام، وفقاً لشدة العقوبة.
- ٣- قانون العقوبات يوضح أنواع العقوبة وشدتها، وكيفية سقوطها أو الإعفاء منها، مع مراعاة ظروف الجريمة لتخفيفها أو تشديدها، ويبين أركان الجريمة: المادي (السلوك والنتيجة والسببية) والمعنوي (القصد وعلم الجاني بجريمته).

٢- القسم الثاني : القسم الخاص من قانون العقوبات :

قانون العقوبات يحدد الأحكام الخاصة بكل جريمة، والجرائم قد تستهدف الدولة مثل التزيف والرشوة والتجسس، أو الأفراد مثل القتل والسرقة، أو تتعلق بالشرف والعرض كالزنا والقدف.

ثانياً : قانون الإجراءات الجنائية :

قانون الإجراءات الجنائية يحدد القواعد الشكلية الواجب اتباعها عند وقوع الجريمة، مثل التحقيق، القبض، الحبس الاحتياطي، إحالة الدعوى، سير المحاكمة وطرق الطعن، دون التطرق لموضوع الجريمة نفسه، بخلاف قانون العقوبات الذي يختص بأركان الجريمة وشروط الإسناد.

الفصل الثاني : فروع القانون الخاص

تعريف القانون الخاص :

هو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع بعضهم، سواء كانت علاقات أسرية أو مالية، ويُعد القانون المدني أهم فروع له لأنه الأصل الذي تفرعت منه باقي الفروع.

المبحث الاول : القانون المدني :

القانون المدني هو أساس القانون الخاص، ويشمل القواعد التي تنظم العلاقات المالية بين الأفراد. أما مسائل الأحوال الشخصية في مصر فتُنظم حسب الدين؛ بالشريعة الإسلامية للمسلمين والشرائع المليية لغير المسلمين. ويُعد القانون المدني الشريعة العامة في القانون الخاص، فيُطبق إذا لم يوجد نص خاص في فرع آخر ينظم المسألة.

لموضوعات التي ينظمها القانون المدني :

أولاً : العلاقات المالية :

العلاقات المالية هي ما يتعلق بالنشاط المالي للأفراد والقواعد التي تنظم الروابط المالية بينهم، وتُسمى بالأحوال العينية أو المعاملات المالية، وتشمل نوعين من الحقوق. وهم الحقوق الشخصية والحقوق العينية

١- الحقوق الشخصية :

هي علاقات تنشأ بين الأفراد يترتب عليها حقوق مالية، بحيث يكون أحد الطرفين دائناً والآخر مدينًا، ويلتزم المدين بمقتضاها أن يؤدي شيئاً أو يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل.

٢- الحقوق العينية :

هي سلطة الشخص على شيء معين تمكّنه من استعماله والتصرف فيه، مثل حق الملكية.

ثانياً العلاقات الأسرية :

العلاقات الأسرية هي روابط الأحوال الشخصية بين أفراد الأسرة، مثل الزواج والطلاق والميراث والنسب. ولم ينظمها القانون المدني المصري بل تركها للقواعد الدينية، بينما يختص بتنظيم العلاقات المالية. وقد صدر القانون المدني المصري الحالي سنة ١٩٤٨ وبدأ تطبيقه سنة ١٩٤٩.

المبحث الثاني : القانون التجاري :

هو مجموعة القواعد التي تنظم الأعمال التجارية

خصائص القانون التجاري :

أولاً : القانون التجاري مرتبط بالقانون المدني ارتباطاً فرع بالأصل، لذلك إذا لم يوجد نص في القانون التجاري يُرجع إلى أحكام القانون المدني.

ثانياً : العرف يلعب دوراً كبيراً في إنشاء قواعد القانون التجاري. إلى جانب النصوص التشريعية، يُعد العرف من المصادر الهامة له.

القانون البحري : القانون البحري ينظم العلاقات والقواعد الخاصة بالملاحة والتجارة البحرية، مثل السفن والعقود البحرية والتأمين على البضائع. ونشأ من القانون التجاري لكنه فصل عنه بسبب المخاطر وحجم السفن وبعدها عن رقابة أصحابها.

القانون الجوي : القانون الجوي ينظم العلاقات الخاصة بالملاحة الجوية، مثل ملكية الطائرة وجنسياتها وتسجيلها. ويشمل أيضاً أحكام عقد النقل الجوي والمسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالركاب أو الأرض.

المبحث الثالث : قانون المرافعات المدنية والتجارية :

قانون المرافعات المدنية والتجارية يحمي العلاقات القانونية المدنية والتجارية وينظم إجراءاتها.

وينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية الموضوعات الآتية :

أولاً : النظام القضائي :

ينظم القانون أصول النظام القضائي، وتشكيل المحاكم، وشروط عمل القضاة والمستشارين، وعمل أعوان القضاء والمحامين والخبراء.

ثانياً : الاختصاص القضائي :

القانون يوزع ولاية القضاء على المحاكم حسب درجاتها. ينظم الاختصاص النوعي حسب نوع الدعوى والاختصاص المحلي حسب الدائرة الإقليمية. يهدف لضمان سير العدالة بكفاءة ودقة.

ثالثاً : إجراءات التقاضي :

هي الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى، تحقيقها، الحكم فيها، وتنفيذ الأحكام القضائية.

المبحث الخامس : القانون الدولي الخاص :

هو القانون الذي يحدد القواعد الواجب تطبيقها على العلاقات الخاصة ذات العنصر الأجنبي ويبين اختصاص القضاء الوطني في نظرها.

موضوعات القانون الدولي الخاص :

هم تنازع القوانين وتنازع الاختصاص : يشمل القانون الدولي الخاص أيضاً مركز الأجانب والجنسية والمواطن الدولي للشخص. رغم اسمه، هو قانون وطني يطبق من قبل القاضي المصري، ويُسمى دولياً لوجود العنصر الأجنبي فيه.

مصادر القانون الدولي الخاص :

المصدر الرئيسي للقانون الدولي الخاص في مصر هو التشريع الوطني، خاصة مواد المجموعة المدنية وقانون المرافعات.

٢- المعاهدات : إلى جانب التشريع الوطني، تُعد المعاهدات مصدراً للقانون الدولي الخاص لحل تنازع القوانين وتنفيذ الأحكام بين الدول.

٣- العرف : إذا لم يوجد نص مكتوب أو معاهدة، يلجأ القاضي إلى العرف، سواء كان داخلياً داخل الدولة أو دولياً بين عدة دول.

٤- المبادئ المستقرة تشريعاً وفقها :

هي المبادئ المستنبطة من الفقه والقوانين الأجنبية، وتطبق عند عدم وجود نصوص أو معاهدات، كما أشارت المادة (٢٤) من القانون المدني.

المبحث الثاني : مزايا التشريع وعيوبه :

أولاً : التشريع يجعل القاعدة القانونية مكتوبة وواضحة، مما يسهل فهمها ويمنع الخلاف في تفسيرها. كما يساعد الأفراد على معرفة حقوقهم وواجباتهم ويحقق استقرار المعاملات. وهو أدق من العرف لأنه مدون وواضح بينما العرف غير مكتوب وقد يسبب نزاعات.

ثانياً : يمتاز التشريع بقدرته على مواكبة التطورات والاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع، بخلاف العرف الذي يحتاج وقتاً طويلاً لتكوينه.

ثالثاً : من مميزات التشريع أنه عام ويطبق في كل إقليم الدولة على جميع المخاطبين، مما يحقق وحدة المواطنين واستقرار المعاملات، وينظم السلوك مع جزاء يفرضه السلطة العامة عند الحاجة.

رابعاً : من مزايا التشريع أنه يخضع القواعد القانونية للدراسة والتحليل، مما يجعل القانون نتيجة نشاط عقلائي مدروس وملائماً لمواجهة الواقع.

خامساً : التشريع يسمح للدول بالاستفادة من قوانين بعضها البعض، وله الغلبة على المصادر الأخرى بفضل دور الدولة في تنظيم العلاقات الخاصة.

المطلب الثاني : عيوب التشريع

١- التشريع قد يصدر من المحاكم أو السلطات لإحكام سلطة الحاكم ضد رغبات الشعب، وأن المشرع قد لا يراعي نبض الجماهير أو ما يحدث في المجتمع، وأن هذا النقد غالباً ينشأ من سوء الظن بالحاكم أو عدم الثقة بالسلوك الحاكم وغالباً بلا دليل، ويُعتبر تعميماً غير منطقي لأن الواقع يُظهر استمرار التشريعات بشكل منتظم حتى في الدول الديمقراطية.

٢- يُعاب على التشريع أنه جامد ولا يواكب الظروف الجديدة في المجتمع، لكن هذا النقد مردود لأن المشرع يتدخل دورياً لتعديل أو إلغاء أحكامه حسب الحاجة.

٣- من أكبر الانتقادات للتشريع أنه قد يصدر في ظروف انفعالية ومتسعة، لتحقيق مصالح فئة معينة على حساب أخرى، كما حدث في مصر في الستينات، حين صدرت قوانين لصالح العمال والمستأجرين دون مراعاة حقوق الملاك، ويعود ذلك إلى أن صانعي التشريع بشر قد يميلون أحياناً إلى الانتصار لمصالح شخصية أو فئوية على حساب المصلحة العامة.

٤- بعد صدور التقنين قد يُفدس لفترة ثم يتبين عدم عمليته، لكن باختيار المشرعين بعناية وإمكانية تعديل القوانين يبقى التشريع المصدر الأول والأكثر انتشاراً.

المبحث الثالث :

دستور كل دولة يحدد الجهة المختصة بسن التشريع، وهي السلطة التشريعية، وقد تكون فرداً مثل الملك، أو مجلساً منتخباً مثل مجلس الشعب والشورى في مصر. قد يشارك رئيس الدولة في التصديق أو الاعتراض على التشريعات، أو يصدر تشريعاً في ظروف معينة.

أهمية التشريع تحدد الجهة التي تصدره: فالتشريعات المصيرية قد تحتاج إلى هيئة خاصة أو استفتاء شعبي، بينما التشريعات العادية تضعها السلطة التشريعية، والتفصيلية التطبيقية قد تصدر عن السلطة التنفيذية.

تختلف قوة التشريع حسب نوعه وأهميته وتأثيره على مصالح الدولة والمجتمع.

ولهذا ينبغي بيان ذلك :

أولاً : تدرج التشريعات بحسب القوه : تدرج التشريعات حسب أهميتها: الأعلى الدستور، يليه التشريع العادي (القوانين)، ثم التشريع الفرعي (اللوائح والقرارات الإدارية).

لا يجوز للتشريع الأدنى أن يخالف الأعلى، وعند التعارض الغلبة للتشريع الأعلى، ويقوم القضاء بالفصل في ذلك.

ثانيا : انواع التشريعات بحسب درجتها وطريقه اصدارها :

١. الدستور: أعلى التشريعات ويضعه جمعية تأسيسية.
٢. التشريع العادي: القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية مثل مجلس الشعب.
٣. التشريع الاستثنائي: يصدره رئيس الدولة في ظروف خاصة أو حالات الضرورة.
٤. التشريع الفرعي: اللوائح والقرارات الإدارية لتنظيم أعمال الوزارات والهيئات.

المطلب الاول : سن التشريع الأساسي (الدستور) :

التشريع الأساسي هو الدستور، ويحدد شكل الدولة ونظام الحكم، وينظم السلطات العامة واختصاصاتها، ويكفل الحقوق والواجبات الأساسية للأفراد مع ضمان حمايتها.

السلطات المختصة بسن الدستور :

تختلف الجهة التي تضع الدستور حسب الدولة والزمن؛ فقد يكون الحاكم، أو جمعية تأسيسية منتخبة، أو السلطة التشريعية، أو الشعب عن طريق الاستفتاء. وفي مصر: صدر أول دستور عام ١٩٢٣ كمنحة من الملك فؤاد، ثم دستور ١٩٦٤، ثم الدستور الدائم سنة ١٩٧١، وتم تعديله عام ١٩٨٠.

طريقة سن الدستور وتعديله : تختلف طريقة سن الدستور عن طريقة تعديله ...

اولا : طريقة سن الدستور : تنقسم الى ثلاث انواع :

١- الدستور الممنوح : الدستور قد يصدر كمنحة من الحاكم للشعب، مثل الدستور المصري سنة ١٩٢٣ الذي منحه الملك فؤاد.

٢- الدستور الاتفاقي : قد يصدر الدستور كعقد بين الحاكم والشعب يضمن حقوق الشعب.

٣- الدستور الشعبي : قد يضع الشعب الدستور بنفسه عبر هيئة منتخبة أو بالاستفتاء، ويُسمى بالدستور الشعبي، وهو أكثر انواع اساتير .

ثانيا : طريقة تعديل الدستور :

١- الدستور المرن : الدستور المرن هو الذي يمكن تعديله أو إلغاؤه بنفس إجراءات القوانين العادية.

٢- الدستور الجامد :

الدستور الجامد لا يُعدّل إلا بإجراءات طويلة وشروط معينة.

مثال على ذلك الدستور المصري الصادر سنة ١٩٧١. وينص على أن طلب تعديل أي مادة يجب أن يذكر المواد المراد تعديلها والأسباب. وإذا رفض مجلس النواب طلب التعديل، لا يُعاد النظر قبل مرور شهر. وفي حال الموافقة، تُعرض التعديلات على الشعب للاستفتاء لتصبح نافذة.

ثالثا : دستورية القوانين :

الدستور هو أعلى مراتب التشريع، فلا يجوز أن تخالفه القوانين. ورغم ذلك، أثار مخالفة القانون للدستور جدلاً حول ما إذا كان القاضي يمكنه رفض تطبيقه. والمشرع المصري لم يحدد حكماً صريحاً بهذا الشأن، فلم يمنع ولا أتاح للقضاء هذا الحق. واجتهاد الفقهاء والمحاكم يفرّق بين المخالفة الشكلية والموضوعية للدستور. ويظل الحق في مراقبة دستورية القوانين موضوع خلاف ونقاش مستمر.

ولكل حاله من هاتين المخالفتين حكما :

١- المخالفة الشكلية :

في المخالفة الشكلية، نجد ان الفقهاء يتفقون علي ان المحاكم لها الحق في الامتناع عن تطبيق القانون إذا خالف الدستور في الشكل، مثل عدم الأغلبية المطلوبة أو عدم النشر الرسمي أو عدم توقيع الرئيس.

٢- المخالفة الموضوعية :

في المخالفة الموضوعية للقوانين، اختلف الفقهاء حول حق المحاكم في الرقابة الدستورية.

رأي بعضهم: لا يحق للقاضي الامتناع عن تطبيق القانون حتى لو خالف الدستور، لتجنب تعطيل التشريع والإخلال بالفصل بين السلطات.

رأي الأغلبية: يجب على القاضي مراعاة الدستور لأنه أعلى من القانون العادي، فالرقابة الدستورية لا تعد اعتداءً على السلطة التشريعية. والمحاكم أيضاً لها الحق في الرقابة على اللوائح التنفيذية، وهذا الحق تأكد قضائياً من خلال أحكام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا. وبعد صدور القرار بقانون ٨١ لسنة ١٩٦٩، أصبحت المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المختصة بالفصل في دستورية القوانين، وحكمها ملزم لجميع المحاكم.

المطلب

الثاني : سن التشريع العادي :

التشريع العادي هو القوانين التي تنظم سلوك الأفراد ويصدرها مجلس الشعب، بينما رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية حسب الدستور.

المراحل التي مر بها سن التشريع العادي :

أولاً : مرحلة الاقتراح :

عملية التشريع تبدأ باقتراح يمثل الصياغة الأولية للفكرة، ويُناقش حتى يتم الاتفاق بالأغلبية. لرئيس الجمهورية و أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين (المادة ١٠٩ من دستور ١٩٧١). مشروع القانون من رئيس الجمهورية يُحضر عادة بواسطة الخبراء واللجان الفنية في الوزارات. بعد الصياغة الأولية، يُحال المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لصياغته النهائية، ثم يُعرض على رئيس الجمهورية قبل إحالته لمجلس الشعب.

الاقتراح من أعضاء المجلس يُراجع أولاً لجنة خاصة لتقرير جواز نظره قبل إحالة المشروع إلى اللجان المختصة.

٢- ثانياً : المناقشة والتصويت :

بعد فحص مشروعات القوانين من اللجان المختصة، تُعرض على المجلس لمناقشتها والتصويت عليها مادة مادة. تتم الموافقة على المشروع بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُعتبر المشروع قانوناً.

ومن الضوابط التي وضعها الدستور لذلك انه :

- ١- انعقاد المجلس لا يكون صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.
- ٢- المجلس يقرر بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا لم تتحقق أو تساوت الأصوات يُرفض القرار.
- ٣- ويجري التصويت علي مشروعات القوانين مادة مادة .
- ٤- مشروع القانون المرفوض من المجلس لا يُعاد تقديمه في نفس دورة الانعقاد.

ثالثاً : تصديق رئيس الجمهورية :

بعد موافقة مجلس الشعب على المشروع، يُعرض على رئيس الجمهورية الذي له حق الاعتراض أو التصديق. وإذا وافق الرئيس أو لم يردده خلال ٣٠ يوماً، يُصبح المشروع قانوناً. وفي حال الاعتراض، يُعاد المشروع للمجلس لإعادة المناقشة والموافقة بأغلبية ثلثي الأعضاء. واعتراض الرئيس لا يسقط القانون، بل يؤخر إقراره مؤقتاً. يسمى هذا الاعتراض "اعتراضاً توفيقياً" لأنه يهدف للتوافق بين السلطتين.

رابعاً : إصدار التشريع :

بعد موافقة الرئيس أو إعادة إقراره من مجلس الشعب بعد الاعتراض، يصبح المشروع قانوناً، لكن لا ينفذ إلا بإجراء من رئيس الجمهورية كجهة تنفيذية.

فالإصدار : عمل من رئيس الجمهورية مفيد لتحقيق امرين هما :

- ١- إثبات وجود التشريع أي إعلان أن القانون صدر وفق الدستور، ويعد بمثابة "شهادة ميلاد" للقانون الجديد.
 - ٢- الإصدار يتضمن أمراً من رئيس الجمهورية بتنفيذ القانون من قبل جميع جهات السلطة التنفيذية، فيصبح القانون واجب النفاذ.
- الإصدار واجب على رئيس الجمهورية، ولا يجوز له الامتناع أو التأخير، ويمكنه إصداره فور إبلاغه بالقانون دون انتظار مدة الاعتراض الثلاثين يوماً، شريطة عدم استعماله حق الاعتراض.

خامسا : نظر التشريع :

التشريع يصبح واجب النفاذ بإصداره، لكنه لا يُطبق على الأفراد إلا بعد نشره ليعلموا به. النشر يتم في الجريدة الرسمية فقط، ولا يغني عنه أي وسيلة أخرى مثل الصحف اليومية أو الإذاعة أو الإنترنت. النشر واجب لكل أنواع التشريع: الدستوري، العادي، والفرعي. ينشر القانون خلال أسبوعين من إصدار رئيس الجمهورية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي للنشر إلا إذا حُدد موعد آخر. وبعد النشر يُفترض علم الجميع بالقانون، فلا يقبل أحد الادعاء بالجهل به.

المطلب الثالث : سن التشريع الفرعي :

التشريع الفرعي يصدر عن السلطة التنفيذية لتفصيل وتنظيم التشريع العادي وحفظ الأمن والصحة العامة. أنواعه ثلاثة:

١. اللوائح التنفيذية

٢. اللوائح التنظيمية

٣. لوائح الضبط أو البوليس، وتشريع الضرورة

أولا : اللوائح التنفيذية :

اللوائح التنفيذية تصدر لتطبيق القوانين وتوضيح تفاصيلها الدقيقة. رئيس الجمهورية يصدرها وفق المادة ١٤٤ من دستور ١٩٧١، ويمكنه تفويض غيره. يجب ألا تُعدل أو تُعطل القانون أو تُعفي منه. ويجوز تعيين من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ القانون. مثال: القرار الجمهوري ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ لتنفيذ القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١.

ثانيا : اللوائح التنظيمية :

اللوائح التنظيمية تنظم المرافق العامة وسير العمل فيها. وهي مستقلة عن القوانين ويصدرها رئيس الجمهورية. وتهدف لوضع الأسس التفصيلية للإدارة العامة للدولة.

ثالثا : لوائح الضبط :

لوائح الضبط أو البوليس هي لوائح مستقلة تصدرها السلطة التنفيذية ولا تستند إلى قانون مسبق. وتهدف للحفاظ على الأمن العام والسكينة والصحة العامة، لكنها تمس حريات الأفراد وأموالهم مباشرة. يصدرها رئيس الجمهورية وفق المادة ١٤٥ من دستور ١٩٧١.

أمثلة عليها: لوائح المرور، مراقبة الأغذية، منع انتشار الأوبئة، وتنظيم المحال العامة.

تتضمن عقوبات محددة بالقانون، وغالباً غرامة لا تزيد على ٢٥ قرشاً إذا لم ينص اللوائح على عقوبة أخرى.

رابعا : تشريع الضرورة :

تشريع الضرورة يصدره الرئيس في الحالات الطارئة بتفويض ثلثي مجلس النواب. ويُعرض القرار على المجلس بعد انتهاء التفويض، وإذا لم يوافق يُلغى أثره القانوني. ويمكن إصدار قرارات بقوانين في غير دور انعقاد المجلس وعرضها خلال ١٥ يوماً. والرئيس يمكنه الدعوة للاستفتاء في المسائل المصيرية، مع التصويت على كل مسألة منفصلة.

...الرقابة على شرعية اللوائح :

لا يجوز للائحة مخالفة القانون، وأي مخالفة يحق للقضاء الامتناع عن تطبيقها. والقضاء الإداري يمكنه إلغاؤها إذا طعن عليها أصحاب المصلحة. وأسباب الطعن تشمل مخالفة القانون، عيب الشكل، أو سوء استعمال السلطة. ميعاد الطعن ٦٠ يوماً من نشر اللائحة في الجريدة الرسمية. وينطبق ذلك أيضاً إذا خالفت اللائحة أحكام الدستور.

عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون :

نشر القانون في الجريدة الرسمية هو الطريقة الوحيدة لإعلام الناس بالتشريع. وبعد انقضاء المدة القانونية من النشر، يُفترض علم الجميع بالقانون، ولا يُعذر أحد بجهله. والقاعدة تسري على المواطنين والأجانب والسلطات القضائية والتنفيذية. القاضي يفترض علمه بالقانون، والسلطة التنفيذية ملزمة بإصدار قرارات متوافقة مع القانون. وتهدف القاعدة لمنع الفوضى وضمان تطبيق القانون على الجميع.

مبررات هذه القاعده :

قاعدة «لا يعتذر أحد بجهله بالقانون» تهدف لضمان تطبيق القانون على الجميع. وفتح باب الاعتذار يؤدي لعدم تطبيقه وفقدان عموميته. وتطبق غالباً في قوانين العقوبات لأن الجرائم محرمة أخلاقياً ومعلومه للناس. وتؤمن المساواة أمام القانون وتحافظ على النظام الاجتماعي.

نطاق تطبيق المدا :

١- حالة القوة القاهرة :

القوة القاهرة استثناء على قاعدة «لا يجهل القانون». وتحدث عند منع ظروف القاهرة العلم بالقانون مثل الزلازل أو الحروب. والأفراد في المناطق المعزولة يعذرون بعدم علمهم بالقانون.

٢- الغلط في القانون :

في المسائل غير الجنائية يجوز الاحتجاج بالغلط في القانون وفق المادة ١٢٢ من القانون المدني المصري.

مثال: بيع نصيب في شركة بالخطأ معتقداً أنه ربع وليس نصف، فيحق التراجع عن العقد.

الاستناد للجهل بالقانون كعذر لا ينطبق هنا، فالفرق بين الغلط والجهل واضح.

وفي القضايا الجنائية، الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة إلا إذا مانع القصد الجنائي.

مثال: من وجد كنزاً في أرض غيره ولم يعلم نصيبه لا يُعاقب لعدم توافر القصد الجنائي.

٣- في المسائل الجنائية :

الموظف يعفى من العقوبة إذا ارتكب الفعل بأمر رئيسه أو اعتقد مشروعيته. وقاعدة «لا يعتذر أحد بجهله بالقانون» تسري على جميع القواعد القانونية. واستثناء القوة القاهرة محدود بالمدة ويطبق على القوانين المنشورة فقط. والمبدأ يسري على القاضي والأفراد، فيفترض العلم بالقانون. والمحكمة تطبق القانون تلقائياً دون حاجة لإرشاد الخصوم.